

客人员的分成部分予以扣除是否合理。

【法院裁判要旨】

湖北省仙桃市人民法院经审理认为：组织卖淫犯罪所得是指扣除卖淫人员分成后行为人实际获得的嫖资，卖淫人员获得的分成系其个人违法所得，应当在行政处罚中追缴。本案卖淫人员和介绍卖淫人员分成约占嫖资60%，酌情按非法获利的40%认定共同犯罪的违法所得。判决：

- 一、胡某某犯组织卖淫罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金30万元；
- 二、杜某某犯组织卖淫罪，判处有期徒刑十年八个月，并处罚金30万元；
- 三、刘某某犯组织卖淫罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金25万元；

四、王某某犯组织卖淫罪，判处有期徒刑七年八个月，并处罚金10万元；

五、李某某犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金3万元；

六、对胡某某、杜某某、刘某某、王某某共同违法所得407280元依法予以追缴，上缴国库；

七、对李某某违法所得2万元依法予以追缴，上缴国库；

八、扣押在案的记账本、招嫖卡片予以没收，由公安机关依法处理。

胡某某、杜某某、刘某某、王某某提出上诉。

湖北省汉江中级人民法院经审理认为：无论卖淫嫖娼还是组织卖淫行为，法律对此类行为持否定性评价，因此行为人由此而获得的经济利益均为非法获利，行为人为此而付出的所谓“成本”，如付给卖淫人员的费用、租赁卖淫场所发生的相关费用等，均属于犯罪成本，依法不能在犯罪所得中扣除。故，本案的非法获利全部为违法所得，原审对卖淫人员、介绍嫖客人员的分成部分予以扣除不当。胡某某、杜某某、刘某某、王某某的共同违法所得1017200元应全部予以追缴。同时，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第十三条第一款规定，犯组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫罪的，应当依法判处犯罪所得2倍以上的罚金。共同犯罪的，对各共同犯罪人合计判处的罚金应当在犯罪所得的2倍以上。据此，对各共同犯罪人合计判处的罚金应当在2034400元以上，原审对各共同犯罪人合计判处罚金950000元，属于量刑不当。但基于“上诉不加刑”原则，二审不加重对各共同犯罪人的罚金刑。据此，判决如下：

一、维持仙桃市人民法院(2022)鄂9004刑初250号刑事判决第一项、第二项、第三项、第四项、第五项、第七项；

二、撤销仙桃市人民法院(2022)鄂9004刑初250号刑事判决第六项、第八项；

三、对上诉人胡某某、杜某某、刘某某、王某某的共同违法所得1017200元依法予以追缴，上缴国库；

四、扣押在案的杜某某的手机4部、王某某的手机2部、李某某的手机3部予以没收，上缴国库；

五、其他扣押在案的物品由公安机关依法处理。

【法官后语】

关于组织卖淫罪中行为人的非法获利是否应全额认定为违法所得的问题。

从法益保护的角度判断，全额认定违法所得有利于加强对组织卖淫罪法益的保护。组织卖淫因侵害人身权利、破坏社会伦理、衍生多种严重犯罪、影响社会安定等原因而成为被我国重刑规制和严厉打击的对象。从《中华人民共和国刑法》第三百五十八条的规定可知，一旦构成本罪，对行为人在五年以上十年以下量刑，其起刑点高于很多妨害社会管理秩序类的其他罪名，而若达到法定刑升格条件，构成“情节严重”，则在十年以上有期徒刑或无期徒刑范围内量刑。因此，本罪若将行为人获取的全部嫖资均认定为违法所得和非法获利，不扣除任何成本，能够最大限度剥夺行为人再犯罪的能力，有利于加强对法益的保护力度。

从刑法学基本原理判断，违法所得和非法获利内涵一致符合量刑均衡原则。量刑均衡原则是我国刑法的重要原则之一，它要求法官量刑时不仅要做到罪责刑相适应，同一案件所判处的刑罚还应当符合均衡原则。非法获利是法定刑升格的依据之一，违法所得影响罚金数额及追缴金额大小，二者均为定罪量刑提供依据和标准，以行为人获取的经济收益来衡量违法严重性，在作用上并无二致，应具有同一标准。本案组织者的非法获利数额在100万元以上，对其主刑的量刑适用十年以上有期徒刑或者无期徒刑，若扣除卖淫人员个人违法收入，比如本案一审扣除60%，犯罪所得将会大打折扣，其适用罚金刑以及追缴犯罪所得范围适用标准随之降低，由此而产生附加刑的惩治力度不能与主刑相匹配的问题，不免量刑失衡。反之，若法定刑升格、罚金适用、追缴范围使用同一标准，便可以保证主刑和附加刑之间的量刑平衡，真正达到罪责刑相适应。

从罪犯构成角度判断，卖淫人员的卖淫行为、介绍嫖客的介绍行为和整个卖淫活动是不可分割的部分。组织卖淫罪是指通过招募、雇佣、强迫、引诱、

容留与等手段，控制他人从事卖淫活动的行为。卖淫人员的卖淫行为、介绍嫖客的介绍行为是犯罪构成不可分割的整体，应进行整体评价。同时，卖淫人员与招募、运送人员或者保镖、打手、管账等人员均为组织者所管理和控制的人员，仅分工、地位等不同，如果对于卖淫人员、介绍人的收入予以扣除，那么对其他人员工资、场地费、食宿费等支出的犯罪成本是否也应予以扣除？若犯罪所得不足以支付犯罪成本，又如何自处。不同于侵犯知识产权类等犯罪，组织卖淫本身建立在违法基础之上，并没有包含正当的经营活动，不能扣除正当的经营成本，而卖淫人员的个人违法收入本是犯罪成本的一部分，所以不应予以扣除。

从刑事审判与行政执法的角度判断，扣除卖淫者的违法所得易形成打击漏洞。在司法实践中，囿于组织卖淫活动的持续性较长、卖淫人员流动性较大、当场查处的卖淫人员较少以及嫖资分成情况取证困难等，组织卖淫罪中涉案的卖淫人员不能全部到案，甚至大部分不能到案，以及卖淫人员的卖淫次数以及获取的嫖资难以精确计算，对于卖淫人员的个人违法所得不能确保全面追缴。若将该项排除在组织者的违法所得之外，将形成对组织卖淫行为的打击漏洞。此外，即便对卖淫人员的个人违法所得在行政执法中已予以追缴，因刑法上组织卖淫罪打击和追缴的对象是组织者，与承担行政违法责任的卖淫人员无关，即使刑事判决涉嫌重复追缴，也并未对卖淫人员重复执法。

综上，在组织卖淫罪中，对于行为人获取的全部嫖资，全额认定为违法所得，符合我国刑法学的基本原理和立法本意，顺应我国打击卖淫刑事犯罪的政策需要，在司法实践的操作上具有便利性和可行性。

编写人：湖北省汉江中级人民法院 谢甜露

组织卖淫者未从嫖资中抽成，仅间接获利的， 违法所得仍应以全部卖淫所得认定

——许某某组织卖淫案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省无锡市中级人民法院(2023)苏02刑终229号刑事裁定书

2. 案由：组织卖淫罪

【基本案情】

许某某于2019年6月投资成立了传媒公司，主要从事KTV（提供卡拉OK影音设备与视唱空间的场所）娱乐业务。后许某某为吸引客源、提升KTV经营效益，同意李某某、熊某等人招募卖淫人员提供有偿陪侍和卖淫服务，并通过规定卖淫价格及抽成比例、禁止私自卖淫、组织逃避检查等管理手段，长期开展组织卖淫活动。

2021年以来，李某某担任传媒公司总经理，负责传媒公司内日常经营管理，包括招聘、面试卖淫人员、确定卖淫人员的卖淫价格、召开管理层例会等事项。熊某、闫某、张某担任服务二部负责人，共同负责卖淫人员签到、安排试房、召开例会等工作。其中，熊某负责卖淫人员的初次面试定价；闫某负责提供卖淫房间；张某经许某某授意，传达许某某关于组织卖淫的相关指令，同时负责向卖淫人员售卖台票。王某、张某1担任业务部负责人，共同管理业务经理，召开部门例会，传达公司规定，其中业务经理与公司签订销售业绩合同，负责联系客户拓展业务，为客户介绍卖淫人员并安排卖淫事宜，通过包厢消费

一、妨害社会管理秩序罪 211

提成和卖淫人员嫖资抽成牟利。夏赞华担任服务一部负责人，负责管理服务员，召开部门例会，传达公司关于卖淫的制度及规避检查的措施。服务员记载卖淫费用、房间费用，为业务经理结算卖淫费提供帮助。

2021年以来，许某某及李某某、熊某等人共组织29名卖淫人员从事卖淫